

1509234-92.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... a prática do delito de tráfico de entorpecentes em concurso com o adolescente infrator.

Em juízo, o policial Jonathan disse que é um caso antigo e, por isso, se lembra pouco. Narrou que estava patrulhando e teve uma denúncia de uma pessoa que chegou até a viatura, informando que estava tendo tráfico num beco, e chegando próximo ao local, os policiais viram indivíduos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509234-92.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509234-92.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO ANJO NUNES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

FABRICIO ANJO NUNES DOS SANTOS (RG: 52642576) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque o dia 14 de abril de 2021, por volta das 21h45min, em ocasião de calamidade pública, na Rua Georg Ebers, 15, Jabaquara, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado com unidade de desígnios e propósitos com o adolescente John Macley Capua Lima, teria trazido consigo e guardado, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 960.6g (novecentos e sessenta gramas e seis decigramas) de maconha, 71.3g (setenta e um gramas e três decigramas) de cocaína, além de 505.1g (quinhentos e cinco gramas e um decigrama) de cocaína na forma de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi preso em flagrante (fls. 5/7), e sua prisão foi convertida em

preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 66/69).

O acusado foi notificado/citado (fl. 110) e apresentou Defesa Prévia (fls. 115/121).

A denúncia foi recebida e concedeu-se liberdade provisória (fls. 129/132) e o alvará de soltura foi cumprido (fls. 139/143).

Sobreveio acórdão da superior instância em que deram provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva (fls. 151/158) e o mandado de prisão foi cumprido (fls. 195/196).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas policiais e, ao final, houve o interrogatório.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com aumento da pena.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu diante da ilicitude das provas e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, bem como a fixação da pena no mínimo legal; o afastamento da agravante da calamidade pública; o reconhecimento da menoridade relativa; o reconhecimento do tráfico privilegiado; o afastamento da majorante de participação do adolescente; a fixação de regime aberto com substituição por restritiva de direitos; a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os laudos periciais das substâncias apreendidas constatarem e confirmaram (fls. 23/26 e 105/107) que se tratavam de 960.6g (novecentos e sessenta gramas e seis decigramas) de maconha, 71.3g (setenta e um gramas e três decigramas) de cocaína, além de 505.1g (quinhentos e cinco gramas e um decigrama) de crack.

As testemunhas policiais Guilherme Augusto Ramos dos Anjos e Jonathan Neves de Sousa narraram, extrajudicialmente, que por volta das 21h45 do dia 14/04/2021, realizavam patrulhamento ostensivo motorizado, quando visualizaram o indiciado FABRICIO e o adolescente infrator John Macley em atitude suspeita na via pública. Disseram que assim que avistaram a viatura da Polícia Militar, eles correram na tentativa de fugir do local. Os policiais militares relataram que o adolescente infrator dispensou na via pública uma bolsa e que, em seguida, somente este foi abordado e revistado, em cuja posse não foi encontrado nada digno de registro, entretanto, dentro da bolsa dispensada pelo adolescente infrator foram encontradas 50 unidades de cocaína, e ao ser indagado a respeito dos fatos, John Macley confessou-lhes a prática do delito de tráfico de entorpecentes em concurso com o réu e disse-lhes ainda que o restante das drogas estava na casa do acusado, que se localiza próxima ao local da abordagem. As testemunhas policiais informaram que, em ato contínuo, foram com o adolescente infrator até o local indicado (viela Pedro Álvares Cabral, 37, Americanópolis), onde encontraram o denunciado no interior do imóvel, não tendo sido encontrado nada digno de registro na posse dele, mas logo após vistoriaram a casa e localizaram no quarto do réu, mais precisamente dentro de uma estante de roupa, uma bolsa contendo no seu interior 262 unidades de maconha, 34 unidades de cocaína, 1.886 unidades de "crack", 2 balanças de precisão, algumas folhas de contabilidade, além de R\$ 74,00 em espécie. Por fim, ao indagarem o acusado a respeito dos fatos, contaram que ele confessou-lhes a prática do delito de tráfico de entorpecentes em concurso com o adolescente infrator.

Em juízo, o policial Jonathan disse que é um caso antigo e, por isso, se lembra pouco. Narrou que estava patrulhando e teve uma denúncia de uma pessoa que chegou até a viatura, informando que estava tendo tráfico num beco, e chegando próximo ao local, os policiais viram indivíduos correndo e se desvencilhando de uma bolsa. Relatou que pegaram o adolescente, que informou que, numa residência próxima, homiziavam o restante das drogas, então foram até o local, e entraram na residência com autorização do menor, onde, dentro do quarto, se não se engana no armário, acharam mais drogas. Informou que, em primeiro momento, só o adolescente foi apreendido, e depois, também o réu, dentro da residência. Aduziu que, pelo que se lembra, havia bastante crack, dinheiro, anotações de contabilidade, e ambos os abordados confessaram a traficância. Respondeu que não lembra se era a casa era uma residência ou se era usada apenas como depósito, mas havia colchão, móveis, fogão, e não lembra se os dois moravam lá. Explicou que, primeiramente, só os dois PMS

participaram da abordagem, mas depois pediram apoio e, pelo que lembra, havia uns 8 ou 9 policiais ao todo. Asseverou que a pessoa que fez denuncia não foi identificada, e falou de forma resumida e anônima. Aduziu que fez a patrulha em viatura de 4 rodas e o beco era num lugar bem próximo. Alegou que só visualizou um dos indivíduos, pois estava do lado direito da viatura, e o parceiro viu o outro. Assegurou que foi ele quem apreendeu o adolescente John e que recuperou a bolsa que o adolescente jogou, em cujo interior foram encontradas drogas. Disse que não se lembra da distância entre o beco e a casa, mas foram a pé, pois não dá para ir de viatura, e que o adolescente os acompanhou. Falou que não lembra quem era o dono do imóvel entre os dois que foram abordados. Explicou que o FABRÍCIO estava na sala, e havia um outro cômodo no final, onde estava o fogão, bem destruído e não sabe se funcionava, e ainda tinha o quarto, que foi onde foi localizada a droga, dentro do armário. Asseverou que o local estava aberto e que o consentimento de entrada foi apenas verbal.

Em juízo, o policial Guilherme narrou que estavam em patrulhamento e, quando adentraram a via, viram dois indivíduos, que, ao verem a viatura, correram, e não conseguiram pegar os dois, mas um deles dispensou uma mochila e, com ele nada de ilícito, porém, indagado, confessou que estava no tráfico e avisou para onde o outro poderia ter se evadido, então foram até o local onde estava o réu, que confessou a traficância, e num cômodo foram encontradas mais drogas. Aduziu que o vizinho não quis se identificar e avisou que há uma semana teria chegado grande quantidade de drogas que estava escondida numa casa no interior da viela. Afirmou que viu o adolescente e o réu fugindo, e o menor jogou a mochila, dentro da qual tinha cocaína, umas 50 porções, não lembra bem a quantidade, enquanto o réu foi detido dentro da residência. Explicou que era uma comunidade com moradores, e a casa era um barraco de alvenaria, e tinha um cachorro, era uma residência normal, e acredita que morava gente, pois tinha cama, cômoda, chuveiro. Informou que só o réu estava na residência e não sabe precisar se o adolescente morava lá, pois este estava nervoso, com fala desconexa. Aduziu que tinha cocaína, maconha, pouca quantidade em dinheiro, pedras de crack, dentro e atrás de uma cômoda. Respondeu que, em princípio, ele e o companheiro participaram da abordagem, e depois chamaram apoio e chegaram uns 4 policiais, não se lembra exatamente, mas foram mais 2 viaturas. Esclareceu que um senhor denunciou verbalmente sem se identificar, e falou que dentro da viela haviam pessoas traficando, e que naquela semana havia chegado drogas, e indicou que possivelmente guardavam no final da viela, e a casa realmente era no final da viela, subindo uma escada. Asseverou que a distância não dá nem 100 metros do local até a casa. Falou que o local estava escuro, era à noite, então houve perda de vista, que tinha iluminação, mas a luz era bem fraca. Respondeu que viram duas pessoas se evadindo, então o parceiro pegou o adolescente e ele ficou na segurança da viatura, chamou apoio e depois que chegaram os outros policiais, conversaram com o adolescente e foram até a casa. Disse que o adolescente falou que a casa estaria aberta, então foram até lá e estava realmente aberta, e encontraram o réu num quarto, sentado ao lado da cama. Relatou que o menor deu autorização à entrada e não se lembra se foi formalizado a autorização, e provavelmente teria juntado aos autos se tivesse essa autorização, mas disse que as portas e janelas estavam abertas e o local foi indicado pelo adolescente. Explicou que a casa era pequena, com 2 ou 3 cômodos e não lembra quem precisamente localizou as drogas, foi a equipe toda.

O acusado, em seu interrogatório extrajudicial, declarou somente que nega os fatos que lhes são imputados e que não foi agredido por nenhum policial.

Em juízo, o réu negou os fatos. Explicou que a casa é sua e foi até o local para cobrar o aluguel da inquilina, Flávia, mas ela não estava lá, e quando estava adentrando, chegaram os policiais. Disse que o contrato de aluguel é verbal e ele cobra 500 reais mensais. Falou que a inquilina estava lá fazia um ano e que foi lá só para pegar o dinheiro do aluguel, e chegaram os policiais, que o pegaram, chamando-o pelo nome, e o algemaram. Relatou que eles entraram e foram revirando. Disse que já estava dentro da casa, que tinha acabado de entrar, e foi na hora que os policiais entraram. Esclareceu que entrou até a cozinha, entre a cozinha e a sala. Alegou que morava perto, a uns 4 a 5 quarteirões. Negou que a droga seria

dele. Aduziu que não chegou a ver o adolescente, que só o viu quando chegou a outra viatura, mas não estava junto com ele.

Pelo que se depreende dos autos havia uma denúncia anônima informando sobre a traficância no local dos fatos, indicando inclusive sobre o possível local onde as drogas, que haviam chegado recentemente, estariam armazenadas. Agentes da polícia militar, com base nessas informações, diligenciaram e localizaram dois indivíduos que fugiram. Um deles, um adolescente, foi abordado e, numa mochila desvencilhada pelo menor, foram encontrados entorpecentes. Segundo os policiais, o adolescente teria indicado para onde o outro teria corrido e onde mais drogas estavam guardadas, e, com a autorização do menor, adentraram o imóvel onde foi preso o réu e foram encontradas mais drogas.

Sem avançar no mérito das questões relacionadas à autoria, verifica-se que os policiais efetuaram uma ação precipitada, uma vez que, para que houvesse a devida apreensão das drogas naquele imóvel, os policiais, com posse da informação prévia da existência de traficância naquele local, deveriam ter a devida autorização de ingresso por meio de um mandado de busca e apreensão. Não foi o que aconteceu. O réu, em que pese informar que era dono do imóvel, disse que não morava ali, pois alugava a uma terceira pessoa e tinha acabado de chegar ao local para cobrar o aluguel. Levantou-se a dúvida de quem seria o dono do imóvel, porém é indiferente quem seja o proprietário. Argumentou o Ministério Público que se o dono ou o morador não estivesse presente para objetar a entrada sem autorização, ou que não contestasse posteriormente, seria válida a entrada dos policiais no local. Consigne-se, porém, que não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem a propriedade do imóvel, nem foi indagado ao réu se ele possui registro da casa. No mesmo sentido, não é mais aceitável a tese do crime permanente para admitir a busca e apreensão sem a devida autorização judicial, já que foi superada por novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o ingresso dos policiais no imóvel sem autorização judicial ou sem a prova do consentimento do morador, torna ilegal tudo que foi encontrado e, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são nulas todas as provas derivadas do encontro das drogas, não sobrando, portanto, mais nada que incrimine a ré.

Nesse sentido, já decidiu o referido Tribunal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à

residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Vale anotar que a Sexta Turma estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação das provas colhidas nas investigações. 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir:

"1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n. 132/2.20.0001682-3. Expeçam-se, também, alvará de soltura em benefício do paciente e, nos termos do art. 580 do CPP, da corrê.

(STJ. HC: 616.584 – RS. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgado no dia 30 de março de 2021) (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,

ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige. 1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1). 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e

sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial – meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada – legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. 6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento “deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção (*“consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'”*). (*United States v McCaleb*, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando *Simmons v Bomar*, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (*totality of circumstances*). 6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (*North Carolina v. Butler* (1979) 441 U.S. 369, 373; *People v. Ramirez* (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; *U.S. v. Castillo* (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (*Haley v. Ohio* (1947) 332 U.S. 596, 601; *People v. Andersen* (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579. 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, “necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis” (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal – analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial – ao dispor que, “[f]inda a diligência, os executores lavrarão

auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º. 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. 8.1. As decisões do Poder Judiciário – mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição – servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para “enriquecer o estoque das regras jurídicas” (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. 8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (*Weeks v. United States*, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada (“such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action”). 8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o



senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (STJ. HC: ° 598.051 – SP. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado no dia 02 de março de 2021.)

Além disso, há dúvidas se realmente a pessoa que teria sido visualizada junto ao adolescente e que empreendera fuga era a mesma pessoa que foi encontrada na casa, o que poderia configurar uma prisão em flagrante delito e autorizaria sua prisão dentro da residência. Note-se que apenas um dos policiais aduziu que teria visto os dois indivíduos, e ela própria informou que o local era mal iluminado o que dificultaria um efetivo reconhecimento.

Verifica-se, inclusive que houve uma pequena contradição na fala dos policiais, já que um dos agentes informou que o réu estava na sala e que as drogas foram encontradas no quarto, enquanto o outro agente disse que o réu estava no quarto, ao lado da cama.

Por fim, ambos os policiais informaram que o adolescente teria confessado informalmente a traficância e indicado onde estariam as demais drogas, levando os agentes até o local onde o réu foi preso. Contudo, o adolescente, ao menos da fase policial (fls. 11) e na audiência de apresentação (fls. 100/101), sempre negou os fatos. E isso gera dúvida se foi o adolescente quem indicou a casa em que a maior parte das drogas estavam ou se teria sido o denunciante anônimo.

Portanto, de rigor, o reconhecimento da ilicitude da prova localizada dentro do imóvel, já que obtida por meio de invasão de domicílio, com a sua conseqüente absolvição por ausência da materialidade do crime de tráfico.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu FABRICIO ANJO NUNES DOS SANTOS (RG: 52642576) da imputação de ter infringido o disposto no artigos 33, caput, e 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Fica autorizada a destruição dos objetos e das drogas apreendidas.

Apesar da absolvição, verifica-se que o dinheiro foi apreendido junto com as drogas, e provavelmente se trata de bem proveniente da prática de tráfico, razão pela qual decreto o seu perdimento em favor da União, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA